

次の【事例】及び【判旨】に関する後記アからエまでの各【記述】を検討し、正しい場合には1を、誤っている場合には2を選びなさい。

【事例】

甲は、友人乙及び丙女と深夜歩道上で雑談していたところ、通り掛かったVから因縁を付けられ、Vが丙女の髪をつかんで引きずるなどの暴行を加えたため、乙と共に、丙女への暴行をやめさせるためにVの顔面を殴るなどした（以下、甲と乙が共にVの顔面を殴るなどした行為を「第1行為」という。）。Vは、一旦丙女への暴行をやめたものの、その後も甲らに悪態をついたため、更に乙においてVの顔面を殴ったところ（以下、乙がVの顔面を殴った行為を「第2行為」という。）、Vが転倒して重傷を負った。第2行為の際、甲はVに対し暴行を加えることも、乙の行為を制止することもなかった。

【判旨】

相手方の侵害に対し、複数人が共同して防衛行為としての暴行に及び、相手からの侵害が終了した後に、なおも一部の者が暴行を続けた場合において、侵害現在時における暴行が正当防衛と認められる場合には、侵害終了後の暴行については、侵害現在時における防衛行為としての暴行の共同意思から離脱したかではなく、新たに共謀が成立したかどうかを検討すべきであり、共謀の成立が認められるときに初めて侵害現在時及び侵害終了後の一連の行為を全体として考察し、防衛行為の相当性を検討すべきであるところ、甲に関しては、第1行為については正当防衛が成立し、第2行為については乙との間に新たに共謀が成立したとは認められないのであるから、第1行為と第2行為とを一連一体のものとして総合評価する余地はない。

【記述】

- ア. この判旨は、甲らによる第1行為が正当防衛に当たることから、第1行為と第2行為とを一体のものとして考慮するためには、第2行為についての新たな共謀が必要だと考えている。
- イ. この判旨は、甲らによる第1行為が正当防衛に当たることから、甲が乙による第2行為を防止する措置を講じなかったにもかかわらず、甲に共謀関係からの離脱を認めたものである。
- ウ. 共同正犯について「構成要件に該当する違法な行為を共謀することによって成立する」と考える見解に立つと、この事例における甲の罪責について、この判旨と結論において一致することはない。
- エ. この判旨の立場からは、甲に第2行為についての新たな共謀が認められる場合には、甲に過剰防衛が成立する余地はない。

No91

H24-16

正当防衛の共同の射程

正 解

ア 1 イ 2 ウ 2 エ 2

正答率

77%

ア 正しい

最判平6.12.6(百選198事件)は、「侵害現在時における暴行が正当防衛と認められる場合には、侵害終了後の暴行については、侵害現在時における防衛行為としての暴行の共同意思から離脱したかではなく、新たに共謀が成立したかどうかを検討すべきであり、共謀の成立が認められるときに初めて、侵害現在時及び侵害終了後の一連の行為を全体として考察し、防衛行為の相当性を検討すべきである」としている。判旨の結論に賛成する学説は、その理由として、第三者の権利を防衛する場合には、救助の目的を達したとしてその段階で攻撃意思を放棄する者の存在が考えられる以上、その者が自己または第三者の権利の防衛という適法行為に関与したことで不当にも追撃行為にも関与したとされてしまうことのないよう、追撃行為については改めて攻撃意思、さらには共同遂行意思の存在を厳格に再確認する必要があるということを挙げている。

イ 誤っている

最判平6.12.6(百選198事件)は、「侵害現在時における暴行が正当防衛と認められる場合には、侵害終了後の暴行については、侵害現在時における防衛行為としての暴行の共同意思から離脱したかではなく、新たに共謀が成立したかどうかを検討すべきであり、共謀の成立が認められるときに初めて、侵害現在時及び侵害終了後の一連の行為を全体として考察し、防衛行為の相当性を検討すべきである」としている。このように、判旨は、第2行為について、「侵害現在時における防衛行為としての暴行の共同意思から離脱したかではなく」としていることから、甲が乙による第2行為を防止する措置を講じなかったにもかかわらず、甲に共謀関係からの離脱を認めたものではない。

ウ 誤っている

まず、本記述の見解に立った場合の甲の罪責について検討すると、本記述の見解では、「共同正犯は構成要件に該当する違法な行為を共謀することによって成立する」と考えるところ、本事例では、第1行為は正当防衛行為であって適法な行為であり、違法な行為ではないから、本記述の見解によると、第1行為について共同正犯は成立しない。加えて、第2行為については、甲は乙との共謀を交わしていないので、共同正犯は成立しない。それゆえ、本記述の見解では、甲は不可罰という結論となる。次に、本事例における甲の罪責に関する判旨の結論について検討すると、第1行為については正当防衛が成立し、第2行為については新たに共謀が成立したとは認められないため、甲は不可罰である。それゆえ、本事例における判旨の結論は、甲は不可罰というものである。よって、本記述の見解に立つと、本事例における甲の罪責について、判旨と結論において一致する。

エ 誤っている

判例は、「侵害終了後の暴行については、侵害現在時における防衛行為としての暴行の共同意思から離脱したかどうかではなく、新たに共謀が成立したかどうかを検討すべきであって、共謀の成立が認められるときに初めて、侵害現在時及び侵害終了後の一連の行為を全体として考察し、防衛行為としての相当性を検討すべきである」としている。よって、甲に第2行為についての新たな共謀が認められた場合には、一連の行為を全体として防衛行為の相当性を検討し、防衛行為が相当性を欠く場合には、正当防衛の他の要件を満たしている限り、過剰防衛として刑の任意的減軽・免除の対象となる(36条2項)。